

1000969-47.2017.8.26.0472

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Improbidade Administrativa

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos".

(PAZZAGLINI FILHO, MARINO; ELIAS ROSA, MÁRCIO FERNANDO E FAZZIO JÚNIOR, WALDO.

Improbidade Administrativa, E. Atlas, p. 35).

Ressalto, ainda, que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira - 1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valriani, 525 - Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000969-47.2017.8.26.0472 - lauda

CONCLUSÃO

Em 08 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos a(o) Dr.(ª) JOANNA PALMIERI ABDALLAH, MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira. Eu, JOANNA PALMIERI ABDALLAH, Juiz de Direito, J14133, digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000969-47.2017.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa

Requerente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Requerido:

Mauricio Sponton Rasi e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada pelo Município de Porto Ferreira e, posteriormente, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Maurício Sponton Rasi, Construtora Vila Verde, representada por Wlademir Domingos Russi, Édson Pudence e Adriano Ricardo Martins.

Narra, em síntese, a ocorrência de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, nos moldes do artigo 10 da Lei 8.429 de 1992, e, ainda, que atenta contra os princípios da administração, nos termos do artigo 11 da aludida Lei. Aduz que o requerido Maurício, na condição de prefeito de Porto Ferreira, promoveu o contrato nº 37/08, precedido de licitação, com a empresa Vila Verde, com objeto voltado sobre serviços de jardinagem/paisagismo na Avenida do Comércio (Av. João Martins de Oliveira Sobrinho) e que não houve a devida atenção ao procedimento de licitação, nem tampouco à execução do contrato, que se deu com precária fiscalização, acarretando prejuízo ao erário, no valor repassado à empresa, atualizado em R\$ 255.952,12 (fls. 28/29).

Sustenta o autor que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através

do TC-001750/010/11, julgou irregular a contratação da empresa Construtora Vila Verde realizada através da licitação na modalidade tomada de preços nº 02/2008, que originou o contrato nº 37/2008, com fundamento nas muitas falhas de execução contratual registradas pela competente unidade fiscalizadora desta Corte: substituição de equipamentos sem a devida formalização de instrumento contratual, omissão das unidades gestoras da Municipalidade no pagamento antecipado de serviços, antes mesmo de entrega e instalação dos equipamentos e também na ausência de aplicação de penalidades à contratada, dentre outras. A Prefeitura Municipal instaurou processo de Sindicância, P.A. nº 10.220/2016, o qual também verificou as falhas apontadas pelo Tribunal de Contas. Pelo Ministério Público, foi oficiado à Prefeitura, através do ofício nº 40/17, realizasse o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, considerando que o município detém legitimidade, ofício reiterado pelo de nº 138/17.

Aduz, portanto, que restou demonstrada a prática de improbidade administrativa por parte do requerido Maurício Sponton Rasi, pois, na condição de Prefeito Municipal, realizou e homologou o procedimento licitatório facilitando a incorporação de verbas públicas ao patrimônio da demandada, concorrendo, portanto, para o enriquecimento ilícito dessa pessoa jurídica.

Requer o reconhecimento da nulidade que inquina o Tomada de Preços nº 02/2008 e o Contrato Administrativo nº 037/2008, bem como os consequentes pagamentos ilegais noticiados nos autos, em razão da prática de ato de improbidade administrativa; o reconhecimento dos atos de improbidade previstos no art. 10, "caput" e incisos VIII, IX, XI e XII, e art. 11, "caput" e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92; o reconhecimento de que não há condições fáticas de retornar ao status quo ante, sendo de rigor a fixação do prejuízo em pecúnia; a condenação dos requeridos, solidariamente, no dever de indenizar os cofres públicos a título de dano patrimonial; condenação dos requeridos, na medida de suas culpabilidades, nas demais sanções estabelecidas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92; subsidiariamente, acaso não se entenda configurada a prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário, requer o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública, de maneira que se apliquem as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. Juntou documentos às fls. 26/445.

Pedido do Ministério Público para que fosse determinada à emenda a inicial para inclusão de Édson Pudence, diante de a fiscalização do contrato ter ficado a seu cargo, na condição de Diretor do Departamento de Obras, e Adriano Ricardo Martins, pelo fato de os recebimentos provisório e definitivo terem ficado sob sua responsabilidade. (fls. 449/450).

O Município manifestou-se às fls. 456 informando que apenas o então Prefeito foi responsabilizado e apenado com multa.

Às fls. 466/468, foi realizado referido aditamento pelo órgão ministerial, acolhido às fls. 1128/1129, a qual foi objeto dos embargos de declaração apresentados às fls. 1152/1179, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1547/1548.

O Ministério Público aditou a inicial às fls. 466/468 incluindo no polo passivo Édson Pudence e Adriano Ricardo Martins. Inquérito civil juntado às fls. 469/1127.

O réu Mauricio apresentou defesa preliminar às fls. 1180/1217. Alegou, basicamente, que não houve ilegalidades, especialmente quanto à inexistência de orçamentos externos, ao suposto caráter restritivo do índice de endividamento exigido, à substituição de equipamentos, sem a devida formalização de instrumento contratual, ao suposto pagamento antecipado de serviços, à suposta ausência de aplicação de penalidades à contratada, à responsabilidade do gestor do contrato e fiscal do contrato, aos termos aditivos de prorrogação de prazo, à aprovação da execução do contrato pelos órgãos competentes, ao desperdício de recursos públicos; e que houve má-fé no oferecimento da denúncia de improbidade administrativa. Documentos às fls. 1218/1314.

Defesa prévia do réu Edson às fls. 1315/1358, alegando prescrição, inépcia do aditamento apresentado pelo Ministério Público, ausência de litisconsórcio necessário com relação à comissão de licitação, ao ordenador de despesas, ao procurador, ao próprio Município, à ex prefeita Renata Anchão Braga; no mérito,

afirma que o réu atuou diligentemente na fiscalização da obra, não havendo dolo ou culpa, que teria a obra teria sido entregue após Edson ter saído do cargo. Documentos às fls. 1359/1447.

Defesa prévia do réu Adriano às fls. 1148/1460, alegando falta de responsabilização da Comissão de Licitação, ilegitimidade dos questionamentos sobre pagamentos, ausência de litisconsórcio necessário quanto ao procurador e ao município pela omissão; no mérito, impugna os argumentos lançados na inicial. Documentos às fls. 1461/1546.

Defesa preliminar da ré Construtora Vila Verde às fls. 1549/1567, argumentando que não há o menor indício de existência de ato ímprobo na condução do certamente, tampouco a existência de qualquer favorecimento à requerida, que apresentou o melhor preço e a proposta mais vantajosa ao Poder Público. Documentos às fls. 1568/1594.

Manifestação do Município às fls. 1603/1604 quanto às defesas preliminares.

Manifestação do Ministério Público às fls. 1607/1612 quanto às defesas preliminares.

Decisão de fls. 1615/1621 recebendo a inicial, afastando as preliminares, recebendo a inicial e determinando a citação dos réus.

Embargos declaratórios opostos pelo réu Edson às fls. 1632/1643, rejeitados às fls. 1656/1657.

Embargos declaratórios opostos pelo réu Edson às fls. 1658/1661.

O requerido Adriano contestou a ação às fls. 1663/1677, pleiteando, preliminarmente, pela nulidade do feito, haja vista tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, não tendo sido a comissão de licitação, o ordenador de despesas, o Procurador do Município e o próprio ente federativo arrolados no polo passivo da demanda; bem como pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, fundamentada na impossibilidade jurídica do aditamento da inicial pelo Parquet. No mérito pleiteou pela improcedência da ação.

O réu Edson requereu tutela provisória incidental de urgência de natureza cautelar às fls. 1682/1687.

O réu Edson contestou a ação às fls. 1688/1731, pleiteando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição, pela impossibilidade de aditamento da inicial pelo Parquet, bem como sua inépcia, pela nulidade do feito pelo desrespeito ao litisconsórcio passivo necessário. No mérito pleiteou pela improcedência da ação.

A ré Construtora Vila Verde contestou a ação às fls. 1732/1750, em que não alegou preliminares. No mérito, afirmou que não há o menor indício de existência de ato ímprobo na condução do certamente, tampouco a existência de qualquer favorecimento à requerida, que apresentou o melhor preço e a proposta mais vantajosa ao Poder Público.

O réu Maurício contestou a ação às fls. 1755/1798, impugnando, preliminarmente, o valor da causa, bem como requerendo o sobrestamento do presente feito, considerando a repercussão geral dos temas 576 e 309 do Supremo Tribunal Federal. No mérito pleiteou pela improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 1799/1857.

Agravo de instrumento interposto pelo réu Edson não conhecido (fls. 1861/1868).

O Município manifestou-se acerca das contestações às fls. 1878/1879. Documentos às fls. 1880/1881.

Parecer do Ministério Público às fls. 1888/1907 requerendo o julgamento do feito com a procedência da ação.

Manifestação do réu Maurício às fls. 1908/1929 e 1934/1935. Documentos às fls. 1930/1933.

O réu Edson manifestou-se às fls. 1936/1943.

Manifestação do Ministério Público às fls. 1947.

Decisão de fls. 1948/1949 instando as partes a especificarem as provas a serem produzidas.

Embargos declaratórios opostos pelo réu Edson às fls. 1950/1961.

Manifestação do réu Edson às fls. 1962.

Manifestação do Município às fls. 1965.

Manifestação do Município acerca dos embargos opostos pelo réu Edson (fls.

1966/1967).

O réu Maurício especificou as provas que pretendia produzir às fls. 1968/1972.

A requerida Construtora especificou provas às fls. 1973.

O réu Edson manifestou-se às fls. 1974/1985.

O réu Maurício requereu a extinção do feito às fls. 1991/1997.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 1999/2000.

Decisão de fls. 2002/2003 rejeitando os embargos de fls. 1950/1961, aplicando multa de 2% ao réu Edson e determinando que o Município emende a inicial.

O Município requereu prazo de 30 dias para cumprir o determinado na decisão supra (fls. 2004), concedido às fls. 2009.

O réu Edson interpôs agravo de instrumento às fls. 2014/2034.

Manifestação do Município às fls. 2039/2041. Documentos às fls. 2042/2087.

Manifestação do réu Maurício às fls. 2089/2092.

Manifestação do Ministério Público às fls. 2097.

Rejeitados os embargos opostos às fls. 2014/2034 (fls. 2099/2111).

Decisão saneadora de fls. 2112/2117. Foi recebida a emenda à inicial de fls. 2039/2041; foram rejeitadas as preliminares referentes ao valor da causa e ao aditamento do Ministério Público; foi deferida a produção de prova pericial, documental e testemunhal, sendo indeferidos os pedidos de depoimento pessoal.

Embargos declaratórios opostos pelo réu Edson às fls. 2134/2143.

Embargos declaratórios opostos pelo réu Maurício às fls. 2144/2151.

O Município contrarrazoou às fls. 2156/2158 os embargos opostos pelo réu Maurício.

O Ministério Público às fls. 2171 requereu a rejeição dos embargos e a produção das provas determinadas.

Decisão de fls. 2174/2176 rejeitando os embargos opostos pelos réus Edson e Maurício.

Manifestação do Município às fls. 2184/2185 sustentando ser desnecessária a confecção de nova perícia.

Às fls. 2186/2189 o réu Maurício reiterou seu pedido de extinção do feito.

O Ministério Público às fls. 2193 manifestou-se pela desnecessidade de nova perícia.

O réu Maurício interpôs agravo de instrumento (fl. 2194).

Agravos não conhecidos (fls. 2203/2206 e 2207/2212).

Decisão de fls. 2227 declarando despicienda a realização de prova pericial e instando as partes a especificarem as provas a serem produzidas.

O réu Maurício especificou as provas que pretende produzir às fls. 2229/2231.

A Construtora requerida apresentou rol de testemunhas às fls. 2235/2237.

O réu Edson interpôs agravo de instrumento (fls. 2239/2252), que não foram conhecidos (fls. 2319/2328).

O Ministério Público manifestou-se às fls. 2257, impugnando a oitiva da testemunha Gabriel Pelegrini.

Decisão de fls. 2258/2260 designando audiência de instrução.

Decisão de fls. 2336/2337 determinando a apresentação de procedimento administrativo entre a Construtora ré e o Município.

Decisão de fls. 2379/2380 determinando a busca e apreensão do mencionado procedimento administrativo.

O Ministério Público às fls. 2411/2413 requereu o encaminhamento de cópias de folhas dos autos ao Ministério Público Federal para averiguação de cometimento de crime de desobediência.

O Ministério Público às fls. 2420 se retratou da manifestação supra, uma vez que os documentos solicitados não se encontravam na posse do gerente.

Manifestação do réu Maurício às fls. 2422/2423 requerendo o cancelamento da audiência designada.

Despacho de fls. 2427 cancelando a audiência designada.

Documentos apreendidos na busca e apreensão (fls. 2465/2885).

O réu Edson manifestou-se às fls. 2894/2911 acerca dos documentos juntados.

A Construtora ré manifestou-se às fls. 2914.

O réu Maurício manifestou-se às fls. 2917/2919.

O Município manifestou-se às fls. 2929/2932.

Audiência realizada no dia 21/07/2021, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas. Em continuação, no dia 09/11/2021, foi ouvida uma testemunha.

Alegações finais do Município às fls. 2951/2955,

Alegações finais do Ministério Público às fls. 2956/2971.

Alegações finais da Construtora ré às fls. 2972/2991.

Alegações finais do réu Maurício às fls. 2992/3038.

Alegações finais do réu Adriano às fls. 3039/3047.

Alegações finais do réu Edson às fls. 3049/3053.

O Ministério Público requereu às fls. 3061 o prosseguimento do feito, assumindo, com exclusividade, o polo ativo da demanda.

O réu Edson manifestou-se às fls. 3063/3069.

Alegações finais reiteradas pelo Parquet às fls. 3086.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, inexistente prescrição à pretensão de ressarcimento de prejuízo ao erário, nos moldes do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Sucede que o E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão afeta à repercussão geral nos autos do RE 669069 (Tema nº 666), concluiu que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no Art. 37, § 5º (parte final), da Constituição Federal, diz respeito apenas às demandas originadas de atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais. Como corolário, firmou a interpretação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Assim, afastado a ocorrência de prescrição nestes autos.

Repilo, ainda, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo réu Adriano.

Os requisitos de admissibilidade processuais devem ser analisados pela teoria da asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativos n. 538, 605 e 615; REsp n. 1605470/RJ, Terceira Turma, p. 01.12.2016; REsp n. 1314946/SP, Quarta Turma, p. 09.09.2016; REsp n. 1705311/SP, Terceira Turma, j. 09.11.2017). Por essa teoria, o Juiz deve analisar os requisitos de admissibilidade do processo à luz da versão abstrata, afirmada dos fatos; qualquer fato dependente de prova é questão de mérito. A parte autora pretende responsabilizar o requerido a partir da prova dos fatos que pretende produzir e dos fundamentos de direito que deduziu. Isto é o quanto basta para o reconhecimento da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão em relação ao requerido e dos que a esta resistem. O acolhimento ou não dos argumentos é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Portanto, em tese, em face do afirmado abstratamente na exordial, o requerido tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois poderia suportar, em caso de procedência, a responsabilidade ventilada. Com tais fundamentos, REJEITO a preliminar.

Analisadas e devidamente afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito.

Compulsando os autos, a ação é parcialmente procedente.

A licitação, disciplinada na Lei nº 8.666/93, é "o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formular propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato" (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Manual de Direito Administrativo, Atlas, 21ª ed., 2008, p. 331).

O procedimento licitatório tem seu fundamento na ideia de competição, de forma isonômica, entre aqueles que preencherem os atributos e aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrigações que pretendem assumir. E, ainda, tem duplo objetivo: possibilitar que as entidades alcancem o negócio mais vantajoso e assegurar aos administrados, se assim desejarem, a participação nos negócios que essas entidades realizarão com os particulares.

Importante mencionar, ainda, que a Constituição Federal tem como regra a exigência de licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações (artigo 37, inciso XXI) e concessão e permissão de serviços públicos (artigo 175), firmados pelos entes da administração direta e indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista), salvo os casos especificados na lei

dispensa e inexigibilidade de licitação, previstas nos artigos 24 e 25 da Lei de Licitação.

Todo procedimento licitatório baseia-se nos princípios que norteiam a atividade administrativa, os quais estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.

O princípio da legalidade impõe que o administrador público, em toda a sua atividade funcional, atue de acordo com os mandamentos da lei, não havendo liberdade nem vontade pessoal. Ou seja, deve fazer o que a lei determina e, em caso de dissonância entre a lei e a conduta, esta deverá ser corrigida para se eliminar a ilicitude.

O princípio da impessoalidade, citando HELY LOPES MEIRELLES, decorre do “clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. (...). Este princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º). E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o interesse público”. (in “Direito Administrativo Brasileiro”, 32ª edição, Malheiros Editores, p. 91/92).

Já a moralidade administrativa “constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata, diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito, da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como o 'o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração' (...). O dever de probidade administrativa está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de seus atos” (obra citada, p. 91 e 125).

O princípio da publicidade abrange toda a atuação do Estado, publicidade essa que se dá não apenas sob o aspecto da divulgação oficial de seus atos, mas também propicia a toda população o conhecimento da conduta interna de seus agentes. Seu objetivo é manter a transparência, ou seja, deixar claro para a sociedade os comportamentos e as decisões tomadas pelos agentes da Administração Pública.

Por fim, o princípio da eficiência significa poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. No âmbito da gestão pública é fundamental ser eficiente, pois os serviços públicos devem atender, de maneira satisfatória, a coletividade.

Destaco, ademais, os conceitos de probidade e improbidade administrativa. Conforme as lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA, a probidade administrativa consiste no dever de “o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo, no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa”. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros editores, 2005, p 669).

Por sua vez, a improbidade administrativa pode ser definida como a “a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (estado de Direito, Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos”. (PAZZAGLINI FILHO, MARINO; ELIAS ROSA, MÁRCIO FERNANDO E FAZZIO JÚNIOR, WALDO. Improbidade Administrativa, E. Atlas, p. 35).

Ressalto, ainda, que a palavra “improbidade” decorre do conceito de “falta de probidade”, ou seja, desonestidade ou desonradez. Transposto para o universo jurídico, temos que a improbidade administrativa é a desonradez no exercício da atividade administrativa, é a desonestidade em relação aos procedimentos esperados da Administração Pública, é a corrupção administrativa que se revela pela obtenção

de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário ou pela desídia ou negligência no cuidado da coisa pública.

As condutas que caracterizam a improbidade administrativa estão elencadas na Lei nº 8.429/92: Art. 9º: "Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei"; Art. 10: "Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei"; Art. 11: "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições...", visando coibir o enriquecimento ilícito oriundo de vantagens indevidas, proteger o erário e garantir o respeito aos princípios da administração pública.

Importante frisar também que, considerando que as penalidades para os atos de improbidade administrativa afetam de maneira grave a vida do eventual infrator, a responsabilização dos agentes públicos deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhes são imputados, devendo, ainda, ser evidente o dolo ou a culpa a acompanharem a prática de tais atos.

Para a tipificação de um ato de improbidade, é necessária a demonstração de dolo ou culpa por parte do agente: "Primeiramente, lembra-se que o dolo equivale à vontade livre e consciente, dirigida ao resultado ilícito (dolo direto) e, inclusive, à mera aceitação do risco de produzi-lo (dolo direto ou eventual). A vontade visa à consecução do resultado, ou percebe como provável a ocorrência do resultado e, mesmo assim, pratica-se a conduta. Está presente o consentimento do agente com o evento. Já a culpa existe quando se dá a prática voluntária de um ato sem a atenção ou o cuidado que normalmente são dispensados a fim de evitar um resultado ilícito e lesivo. Não se prever a consequência ofensiva constitui o elemento que distingue uma espécie da outra" (ARNALDO RIZZARDO, Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, 1ª edição, E. GZ, Rio de Janeiro, 2009, p. 504).

Pois bem.

Taciane Biancardi Fernandes Mesquita disse que atuou por seis anos e meio no departamento de licitações da Prefeitura, tendo participado de diversos processos semelhantes aos discutidos nos autos, os quais eram padronizados. Na fiscalização do tribunal de contas era comum visitarem obras em andamento. Sobre a obra em questão não se recorda do período da visita. Ao verificarem falhas na execução da obra são feitos apontamentos. Apenas recentemente tomou conhecimento acerca do parecer da área técnica do tribunal de contas mencionado à fl. 1963. Não se recorda, mas acredita que eventuais alterações no projeto devem ter sido encaminhadas à Caixa Econômica Federal. O edital também é encaminhado. O diretor de departamento de obras é quem fiscaliza a execução do contrato, bem como os engenheiros da Caixa Econômica. Antes de realização do pagamento é feita uma vistoria pela Caixa Econômica. Acredita que a executora tenha sido notificada a regularizar eventuais imperfeições na obra. O ex-prefeito não solicitou que deixasse de agir. Edson era o responsável pela fiscalização da obra. Não tem ciência acerca do desaparecimento do procedimento administrativo instaurado para verificação da regularidade da obra. Questões afetas ao contrato são analisadas pela procuradoria do município. Ocorreram danos no local durante a obra, não se recordando se foram reparadas pela empreiteira. Não atuava à época em que o tribunal de contas fez os apontamentos sobre as irregularidades. Departamento de obras foi o órgão solicitante, à época dirigido por Edson, o qual era o responsável, inclusive, durante a realização das medições periódicas feitas pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal. Ocupava o cargo de confiança, tendo sido nomeada pelo ex-prefeito Maurício.

Simone Cristina Camargo Klein, funcionária pública, disse que atuou por cerca de 7 anos no setor de convênio do município de Porto Ferreira. Não possuía cargo de confiança à época do contrato. Os contratos de repasse de verbas eram analisados pelo setor no qual trabalhava. A prefeitura não poderia realizar pagamentos sem

prévia análise da Caixa Econômica Federal. Os engenheiros da Caixa realizavam vistorias periódicas na obra. Acredita que o Prefeito não assinava contratos sem prévia manifestação da procuradoria jurídica. Não sabe se houve saldo devolvido em razão da obra. Eventuais alterações no projeto passaram pelo crivo do seu setor de trabalho. A obra era fiscalizada pelo departamento de obras e pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal. Não se recorda de irregularidades. Não tem ciência acerca do desaparecimento do procedimento administrativo instaurado para verificação da regularidade da obra. Não tem certeza sobre as reais atribuições do diretor de obras. Teve conhecimento acerca de depredações nas obras. Se setor encaminhava para a Caixa os documentos para a efetivação do pagamento. Não soube informar se foram feitas reparações na obra após as danificações. Seu setor era responsável pelo encaminhamento de medições e cronograma da obra para a Caixa Econômica. Acredita que não tenha havido pagamento antecipado.

Wellington de Carvalho disse que trabalhou na obra. Disse que as lixeiras foram trocadas e que foram instalados bancos com e sem encosto. Foram feitos quiosques. Por fim, disse que os responsáveis pela Caixa Econômica acompanhavam a obra.

Mário José Tognoli disse que trabalhou por dez anos na Prefeitura, exercendo as funções de chefe e diretor de obras. A obra foi acompanhada por engenheiros da Caixa Econômica Federal. Foram feitas algumas alterações no projeto em razão de danificações nas lixeiras e bancos do local, as quais foram comunicadas à Caixa Econômica Federal. O departamento de obras realizou a fiscalização na obra, expedindo notificações, acaso necessário. Comunicava a procuradoria jurídica para a adoção das providências jurídicas cabíveis. Recebeu as lixeiras referente à obra e estava acompanhando de um membro do tribunal de contas. Disse que a obra foi concluída alguns meses após a visita dos auditores do tribunal de contas e que a mesma obedeceu ao estabelecido na tabela SINAPI. A obra foi aprovada pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Turismo. Não se recorda se a contratada foi a responsável pela reparação dos danos ocorrido durante a obra. O diretor de obras tem por função gerir as obras ocorridas no município. Eventuais notificações acerca de irregularidade devem ter sido encaminhadas para a procuradoria jurídica. A obra foi entregue após a exoneração de Edson. Não tem ciência de desaparecimento de documentos no setor. Ocupava cargo comissionado.

Em que pese a prova testemunhal, o conjunto probatório evidencia irregularidades no procedimento licitatório e na execução do contrato. Conforme decidido pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no TC-001750/010/11, houve substituição de equipamentos sem a devida formalização de instrumento contratual, omissão das unidades gestoras da Municipalidade no pagamento antecipado de serviços, antes mesmo de entrega e instalação dos equipamentos e também na ausência de aplicação de penalidades à contratada. (fl. 32/51)

O relatório da fiscalização indica as falhas na execução do contrato: "a) Dos 80 cestos de lixo (em concreto) lançados como instalados na última medição faturada, apenas 14 estavam concluídos; ainda, aqueles instalados eram circulares e não quadrados, bem como seus cestos internos removíveis, que deveriam ser em tela, foram substituídos por placa metálica, cobrindo somente no fundo da lixeira; b) Dos 80 bancos de concreto instalados, apenas 40 tinham encosto; c) Um dos bancos instalados havia sido arrancado, demonstrando má fixação no solo. Sobre tais falhas a Municipalidade informou: a) Que os 66 cestos de lixo realmente não se encontravam instalados, mas que estavam guardados, os quais foram posteriormente instalados; b) Que as lixeiras circulares foram substituídas por quadradas, sendo seus cestos removíveis, contratados e orçados como sendo confeccionados em tela, igualmente, foram substituídos por apenas uma placa metálica removível instalada no fundo de cada lixeira, por serem mais robustas e de maior facilidade de manuseio, acrescentando prejuízo financeiro ao erário; c) no tocante aos bancos, contratados com encosto, sendo que a metade (40 unidades) eram simples, sem encosto, alegou ter como justificativa a ideia de manter a composição da paisagem urbana, bem como evitar atos de vandalismo praticados nos encostos dos bancos.

Tais justificativas não prosperaram perante a Fiscalização, sendo da mesma maneira em juízo. Como bem salientado às fls. 1047, os argumentos são frágeis e repetitivos, além de evitáveis diante de um planejamento básico.



Restou demonstrando, por outro lado, que as substituições realizadas viabilizaram custos menores do que os contratados, ante a inferioridade do material e, como no caso dos bancos, a utilização de menor quantidade de material.

Quanto ao procedimento licitatório:

“Não consta do processo em análise (cujas cópias foram encaminhadas a esta Corte - pressupondo-se que representem a integralidade dos documentos), as citadas notificações à contratada, bem como não consta tenha sido declarada inidônea à época, ou mesmo suspensão temporária de contratação com a Administração, por conta da inexecução do contrato em análise - artigo 87 e seus incisos III e IV da Lei 8666/93, confirmando a Administração às fls. 442, em resposta à requisição de fls. 441, não ter havido tais providências.

Também não houve aplicação de penalidades, dentre aquelas permitidas e relacionadas no termo contratual, sua cláusula décima segunda, fls. 221, de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei de Licitações e Contratos.

Às fls. 443, encontra-se a declaração de impedimento de licitar com a Administração, expedida em 2010, contra a Empresa Construtora Vila Verde Ltda., todavia, por conta de irregularidades em outra execução contratual, não constando que tenha sido comunicada a esta Corte, de acordo com o artigo 45 das Instruções TCESP nº 02/2008.” (fls. 1039/1049)

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos, o qual demonstra a irregularidade no certame, bem como na execução do contrato e seus aditamentos, resta evidente a lesão ao patrimônio público.

A conduta do réu Maurício, Prefeito Municipal quando dos fatos, se amolda ao imputado, isso porque a realização e homologação de certame manifestamente irregular resultou em lesão às verbas públicas.

Da mesma forma se mostra ilícita a conduta da Construtora ré. Ao participar de certame e executar os contratos, ambos manifestamente irregulares, beneficiou-se de verbas públicas.

Por outro lado, o réu Édson, desempenhando à época a função de Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais, detinha a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. O réu Adriano, por sua vez, Engenheiro/Assessor Técnico Municipal, foi o responsável pelo recebimento da obra. Ambos não exerceram suas funções de maneira eficaz, isso porque diante de todas as irregularidades supracitadas, deixaram de proceder à responsabilização da Construtora, aprovando o frágil e irregular serviço prestado pela mesma. Comprovado dano ao erário e desrespeitados os princípios da Administração Pública, tal como exposto acima, aos requeridos devem ser imputados as condutas expostas nos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, impondo-se a eles as condenações previstas nos incisos II e III, do artigo 12 do mesmo diploma legal, respectivamente.

Dito isso, passo a tratar das sanções a serem aplicadas aos requeridos.

As penalidades trazidas no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa são: a) ressarcimento integral do dano, b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, c) perda da função pública, d) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, e) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e f) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Quanto ao réu Maurício:

No caso concreto, devidamente demonstrado o dano ao erário, cuja quantificação do prejuízo correspondente aos valores indevidamente percebidos deve se dar em sede de cumprimento de sentença.

Quanto à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, não há, nos autos, qualquer prova de enriquecimento ilícito do requerido.

No que se refere à perda da função pública, observo que este não mais ostenta o referido cargo de prefeito.

A suspensão dos direitos políticos é medida de rigor, razão pela qual essa sanção deve ser aplicada ao requerido, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em relação à multa civil, com base na discricionariedade, entendo que é adequada a multa em face do requerido no valor equivalente a 25% do valor do dano aqui considerado.

Por fim, aplico ao requerido a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Quanto à ré Construtora Vila Verde:

Ressarcimento ao erário, cuja quantificação do prejuízo correspondente aos valores indevidamente percebidos deve se dar em sede de cumprimento de sentença.

Quanto à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, este também se dará em sede de cumprimento de sentença.

No que se refere à perda da função pública, nada a apreciar por se tratar de pessoa jurídica.

Em relação à suspensão dos direitos políticos, também não há o que apreciar, uma vez que se trata de pessoa jurídica.

Em relação à multa civil, entendo incabível nesse caso.

Por fim, aplico ao requerido a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Quanto aos réus Édson e Adriano:

As penalidades trazidas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa são: a) ressarcimento integral do dano, se houver; b) perda da função pública; d) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; e) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; f) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

No caso concreto, não restou demonstrado, nos autos, qualquer dano ao erário, de modo que não há razão para qualquer ressarcimento a ser imposto aos requeridos.

No que se refere à perda da função pública, entendo ser desproporcional, uma vez que não comprovado qualquer enriquecimento ilícito ou dano ao erário, sendo a violação dos princípios a única conduta reprovável por parte dos agentes.

A suspensão dos direitos políticos é medida de rigor, razão pela qual essa sanção deve ser aplicada ao requerido, pelo prazo de 03 (três) anos, considerando que sua conduta deve ser punida, mas que não gerou consequências gravíssimas a uma grande quantidade de pessoas.

Em relação à multa civil, com base na discricionariedade, entendo que é adequada a multa em face dos requeridos no valor equivalente a 02 (duas) vezes a remuneração por eles recebidas enquanto nos cargos de Diretor e Assessor, respectivamente.

Por fim, aplico aos requeridos a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para:

i) DECLARAR ilegais e nulos os atos administrativos consistentes no Procedimento Licitatório - Tomada de Preços n. 02/2008 e no Contrato Administrativo n. 037/2008; ii) CONDENAR o réu Maurício Sponton Rasi com fundamento no artigo 10, incisos VIII, IX, XI e XII da Lei nº 8.429/92, às penalidades previstas no artigo 12, inciso II, da mesma lei, sendo elas: restituição (solidariamente com Construtora Vila Verde) aos cofres públicos e à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio em valor a ser apurado em cumprimento de sentença; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; multa civil referente a 25% do valor do dano aqui considerado; e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo

prazo de 05 (cinco) anos.

iii) CONDENAR a ré Construtora Vila Verde com fundamento no artigo 10, incisos VIII, IX, XI e XII da Lei nº 8.429/92, às penalidades previstas no artigo 12, inciso II, da mesma lei, sendo elas: restituição (solidariamente com Maurício) aos cofres públicos e à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio em valor a ser apurado em cumprimento de sentença; e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

iv) CONDENAR os réus Édson Pudence e Adriano Ricardo Martins com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, às penalidades previstas no artigo 12, inciso III, da mesma lei, sendo elas: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; multa civil no valor equivalente a 02 (duas) vezes a remuneração por eles recebidas enquanto nos cargos de Diretor e Assessor, respectivamente; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Em razão da sucumbência, arcarão os requeridos, solidariamente, com o pagamento das custas e despesas processuais.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003, bem como o artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta no prazo de 15 dias, procedendo-se da mesma forma em caso de recurso adesivo.

Após, sem nova conclusão, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do apelo (art. 1010, § 3º do Novo Código de Processo Civil). Remetam-se na ocasião, por malote, eventuais mídias referentes aos autos, certificando-se, nos termos do Prov. 25/2017.

Com o trânsito em julgado, extinta a fase de conhecimento, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, certificada a inexistência de custas em aberto, arquivem-se os autos, devendo eventual cumprimento de sentença observar as regras do Provimento CG 16/2016 (Art. 1.285 a 1.289 das NGCGJ).

P.I.C.

Porto Ferreira, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA